

1529177-95.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/03/2022

... que é por eles conhecido por ser palco do tráfico de entorpecentes e avistaram o réu com um estojo grande de cor azul nas mãos, em atitude típica de tráfico de drogas e por isso, resolveram se aproximar e aborda-lo. Em revista pessoal dentro do estojo, foram encontradas várias porções de crack, maconha e cocaína, além de uma quantia em dinheiro, separada em notas pequenas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529177-95.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529177-95.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS FERREIRA GIMENEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

JONAS FERREIRA GINEMEZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo apurado, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Francisco Alves Bezerra, nº 300, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, com a finalidade de comércio e posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 50 (cinquenta) eppendorff's contendo cocaína em pedra - crack, totalizando 11,2 g (onze gramas e dois decigramas); 83 (oitenta e três) eppendorff's e papérolas contendo cocaína em pó - pesando 34 g (trinta e quatro gramas) e 69 porções de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecido como maconha, totalizando 127,5 g (cento e vinte e sete gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado e apresentou resposta a acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos dois policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público buscou a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa requereu a absolvição do réu, nos termos do art 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, o reconhecimento da atenuante da

confissão espontânea, e sua compensação com a agravante da reincidência, a aplicação do redutor disposto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, fixação de regime semiaberto, a concessão da gratuidade da justiça, bem como a aplicação do disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão das drogas, laudo de constatação de substância entorpecente, laudo de exame químico toxicológico positivo para maconha e cocaína, (fls. 96/98), relatório final da autoridade policial, bem como pela robusta prova produzida na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

O próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática do crime. Disse que realmente se encontrava no local dos fatos, vendendo drogas, pois foi o único, "emprego" que conseguiu e precisava do dinheiro para se sustentar.

A confissão do réu, ao contrário do alegado pela combativa Defensora, foi devidamente corroborada nos autos pelas outras declarações colhidas sob o crime do contraditório.

Ouvidos em juízo, os dois policiais civis Marcello Barrozo Soubihe e Ricardo Augusto Conde, afirmaram que estavam em diligência, no local dos fatos, que é por eles conhecido por ser palco do tráfico de entorpecentes e avistaram o réu com um estojo grande de cor azul nas mãos, em atitude típica de tráfico de drogas e por isso, resolveram se aproximar e aborda-lo. Em revista pessoal dentro do estojo, foram encontradas várias porções de crack, maconha e cocaína, além de uma quantia em dinheiro, separada em notas pequenas, típicas da venda de drogas e diante disso, Jonas foi preso em flagrante e levado à Delegacia local, para a lavratura do boletim de ocorrência.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, a condenação do acusado é medida que se impõe.

De início, observa-se que a quantidade e variedade de droga encontradas na posse do réu, sua forma de acondicionamento, o dinheiro apreendido, os depoimentos dos policiais e ainda confissão do acusado, são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Por outro lado, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a

cumpra a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado, ao contrário, o próprio réu confessou a prática do crime e praticamente narrou os fatos de forma idêntica a dos policiais, fato este que confirma que a posição desta magistrada e acima citada, é realmente a que deve ser adotada, e sem ressalvas.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente específico, já tendo sido condenado definitivamente, pelo delito de tráfico de entorpecentes perante a 3ª Vara Criminal Central (Autos nº 1503155-34.2020.8.26.0228), consoante certidão de fls. 40/42, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Além disso, já foi condenado em outra oportunidade pelo delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, perante a 21ª Vara Criminal Central (Autos nº 1523849-58.2019.8.26.0228), o que será aqui considerado como Maus Antecedentes.

Não se desconhece, que para parte da doutrina e da jurisprudência o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas não tem o condão de agravar a pena do acusado, notadamente em virtude das sanções previstas em seu preceito secundário.

Contudo, isso não quer dizer que tal condenação anterior transitada em julgado, deve ser simplesmente desprezada. Isso porque, se por um lado as sanções são até mais brandas que aquelas previstas em várias contravenções e por isso este entendimento vem sendo adotado, em analogia ao disposto no art. 63, do Código Penal, por outro, fato é que o art. 28 da Lei 11.343/06, não foi descriminalizado, e portanto, deve ser valorado, durante a aplicação da pena. Assim sendo, a pena base será aumentada em 1/6, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, chegando-se ao patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, há que se considerar a reincidência específica do acusado, e ainda que o crime foi cometido em meio à pandemia da COVID 19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, em época em que as restrições governamentais ainda estavam vigentes e de maneira mais severa.

Devendo a pena ser aumentada em mais 1/4, chegando-se a 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Com efeito, no que toca a agravante prevista no art. 61, inciso, II, alínea "j", do Código Penal, respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Egrégios Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP – PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

"(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se

trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

E ainda:

“O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante”.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), “a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda” (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

“Não se exige na linha do que penso – que o agente que se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

Também presente no caso a atenuante da confissão e assim sendo a pena deve ser diminuída em 1/6, perfazendo 6 anos, e 27 dias de reclusão e 606 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria da pena, mostra-se incabível o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente em razão da reincidência específica do acusado, que já deixou claro em seu interrogatório que para ganhar seu sustento, se dedica à venda de drogas, ou seja, à atividades criminosas.

Nesse particular, não há falar em bis in idem pelo simples fato de a reincidência servir agora como fundamento para agravar a pena e também impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, não se vislumbrando, por aqui, qualquer inconstitucionalidade. Isto porque, "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado.

Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, "não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (TJSP, Apel. Crim. nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).

Além disso, "O agravamento da pena pela reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal. Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a recidiva, a qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal." (Rev. Crim. nº 990.09.160794-0, 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira). O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta dessa conclusão: "Não há que se falar em bis in idem na utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da minorante contida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, visto que, consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um mesmo instituto jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da pena, desde que haja comando legal específico nesse sentido. Precedentes." (HC 202.163/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, aplicando-se ao réu JONAS FERREIRA GINEMEZ a pena de 06 anos e 27 dias de reclusão, e 606 dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e ainda em razão da reincidência específica e dos maus antecedentes, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado.

Deixo de computar o período de prisão provisória do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo

juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos parte da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Além disso, prevalecer o entendimento de que a lei não determina o cômputo do período de prisão provisória como meio de antecipar a progressão de regime, mas como critério para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, aquele que sob custódia esteve no curso do processo poderá ser agraciado com progressão, na fase de execução criminal, com novo desconto do período já considerado para beneficiá-lo com regime menos gravoso na sentença condenatória.

Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2º do CPP, a teor do que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.

O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2º do Código Penal.

No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2º. e 3º do Código Penal.

É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.

A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).

Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, Dje 03/06/2019).

"HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)" .(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 10/04/2019).

Incabível no caso em tela, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal. Como se sabe o crime de tráfico é o que sustenta inúmeras facções criminosas que com o dinheiro arrecado pela venda de drogas adquirem armamento de alto calibre e praticam diversos outros delitos colocando em risco toda a sociedade.

Ademais, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Não poderá apelar em liberdade, notadamente em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA